[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

研究論文

사용자 개념 확대론에 대한 재검토

권 혁*

Ⅰ. 문제의 소재
Ⅱ. 사용자 개념에 관한 현행법 상의 규정 내용과 해석론
Ⅲ. 단체교섭제도와 부당노동행위제도 상의 사용자 개념 구별
Ⅳ. 지배개입 행위에 따른 원청회사의 부당노동행위 주체로서의 지위 여부
Ⅴ. 요약 및 결론

Ⅰ. 문제의 소재

종래 원하청관계에 관한 노동법적 문제는 주로 위장도급 여부를 판단하는 것이었다. 하청근로자가 원청회사에 소속된 근로자로서의 지위에 있음을 '확인'하거나, 아예 원청근로자로서의 지위를 '형성'시킬 것인가의 논의가 바로 그것이다. 요컨대 원청회사와 하청근로자 간에 묵시적 근로계약관계를 인정하거나, 불법파견으로서의 실질을 인정하고, 그 법적 효과로서 원청회사와 하청근로자 간의 근로계약체결의무를 부담지우게 된다. 이러한 종래의 논의는 개별 하청근로자와 원청회사 간의 '계약'적 지위를 확인하는 것에 해당한다. 그리고 이러한 논의의 해결책으로서, 소위 위장도급관계임을 근거지우는 다양한 기준이 제시되어 왔다. 그 동안 우리 학계도 -

논문투고일자: 12.11.23, 심사일자: 12.12.12, 게재확정일자: 12.12.26
* 부산대학교 법학전문대학원 교수(부교수), 법학박사

독일 등 다른 선진제국의 과거 경험에서와 마찬가지로- 원하청관계에 대한 위장도급 여부를 판단하는 문제에 집중하여 왔다.[1] 나름대로 그 판단기준을 찾아내기 위해 많은 노력을 하여 왔고, 이러한 노력에 따라 어느 정도 성과를 거둔 것은 사실이다. 하지만 명확하게 "위장도급여부에 대한 판단이 가능해 졌다"라고 단정하기에는 여전히 미흡한 상태이다.[2]

그런데 최근 원하청관계에서의 논의는 하청회사 근로자로 조직된 노동조합과 원청회사 간의 문제로 확대되어 가고 있다. 즉, 집단적 노사관계법 차원에서 원하청관계를 재조명하는 시도가 이루어지고 있는 것이다. 특히 하청노동조합이 원청회사를 상대로 하여, (i) 지배개입을 이유로 한 부당노동행위 책임을 묻고,[3] (ii) 나아가 하청노동조합이 원청회사를 상대로 하여 단체교섭을 요구할 경우, 원청회사가 이에 응하여야 할 의무를 부담하는가 하는 문제가 핵심적 쟁점으로 대두하고 있다.[4]

현행 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')에서는 사용자의 개념을 일원적으로 정의내리고 있다. 현행 노조법 제2조 제2호에 규정하여 두고 있다. 그렇다면 적어도 노조법 상 제반 규정에 적용되어야 할 사용자

---

1) 종래 우리 학계의 연구는 위장도급에 관한 논의에 집중되어 왔다. 예컨대 강성태, "위법파견의 사법(私法)적 효과", 「노동법연구」 제29호, 2010, 67면 이하; 도재형, "사내하도급 관계에서 근로자파견의 인정 기준", 「법조」 제60권 제8호, 131면 이하; 최홍엽, "위장도급에 대한 노동관계법의 적용", 「민주법학」 제25호, 2004, 336면 이하; 조경배, "직접고용의 원칙과 파견근로", 「민주법학」 제19호, 2001, 33면 이하; 이정, "일본비정규직의 현황과 입법정책", 「노동법포럼」 제2호, 2008, 46면 이하; 권혁, "독일에서의 사내하도급 활용 현황과 그 시사점" 「노동법포럼」 제7호, 2011. 34면 이하.

2) 실제로 많은 사례에서 위장도급 여부에 대한 판단은, "다소 도급계약으로서의 속성을 가지는 면이 없지 않지만, 근로관계로 볼 수 있다"거나, 반대로 "근로계약적 요소가 다소 발견되지만, 전체적으로 보아 도급계약으로 보는 것이 옳다"라는 식으로 이루어지고 있다.

3) 이에 관하여도 많은 논의가 있었다. 예컨대 강성태, "지금 왜 사용자인가", 「노동법연구」 제24호, 2008, 1면 이하; 박수근, "간접고용근로자의 집단적 노동분쟁과 쟁점의 검토", 「노동법연구」 제24호, 2008, 23면 이하.

4) 이에 관하여는 김영문, "사내하도급 근로자들의 원청기업에 대한 단체교섭 가부", 「노동법학」 제36호, 2010, 155면 이하; 박제성, "기업집단과 노동법: 노사협의와 단체교섭", 「노동법연구」 제21호, 2006 참고.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

의 개념은 일응 노조법 제2조 제2호에 따른 것이어야 하고, 따라서 노조법 상 사용자의 개념은 단체교섭의 상대방으로서 사용자이든, 지배개입이라는 부당노동행위 주체로서 사용자이든 동일하다고 볼 여지가 크다. 다른 한편 노조법 상의 주된 내용을 이루고 있는 부당노동행위제도와 단체협약질서제도 간 제도적 이질성은 사용자 개념을 일원적으로 파악하는 것을 곤란하게 만드는 면도 있다. 이하에서는 부당노동행위제도와 단체협약질서 간의 관계를 중심으로 하여, 원청회사와 하청회사노동조합 간의 법적 관계를 재조명하고자 한다.

Ⅱ. 사용자 개념에 관한 현행법 상의 규정 내용과 해석론

1. 노동법상 '사용자' 개념에 관한 규정 내용

(1) 규정의 내용

현행 노동법 상에서 사용자 개념은 근기법과 노조법에 각각 규정되어 있다. 우선 근기법 제2조 제2호에서, "사용자란 사업주 또는 사업 경영 담당자, 그 밖에 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행위하는 자를 말한다."고 규정하고 있다. 다른 한편 현행 노조법 제2조 제2호에서도, "사용자라 함은 사업주, 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 말한다"라고 규정되어 있다.

(2) 해석론 상의 공방

이상에서 보듯이 현행 노동법 상의 명문 규정 내용이 거의 동일하다. 그렇다면 근로'계약'관계에서의 사용자 개념과 '단체협약' 상의 사용자 개념이 동일하다는 것을 의미한다고 볼 여지가 크다.

하지만 현실적으로는 근로계약관계 상의 사용자 개념과 단체협약질서

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

상의 사용자 개념은 본질적으로 다르다는 주장(소위 '사용자개념 상대성론')이 설득력 있게 제기되고 있다. 즉, 근로계약관계의 존부와는 별개로, 단체협약질서 상의 사용자 개념이 따로 존재할 수 있으며, 따라서 근기법 상의 사용자 개념과 노조법 상의 사용자 개념은 본질적으로 구별되어야 한다고 한다.[5] 이러한 견해는 다분히 집단적 노사관계법 상 존재하는 부당노동행위의 주체로서 사용자 개념을 인정함에 있어 근로계약의 존부를 묻지 않아야 할 이유가 원하청관계에 있다는 것을 염두에 둔 것으로 보인다. 이를 통해 비록 원청사용자와 하청근로자 간에는 직접적인 근로계약은 존재하지 않더라도(즉, 근기법 상의 사용자인지 여부를 묻지 않고라도), 원청사용자를 노조법상으로는 사용자로 보아, 부당노동행위를 할 수 있는 주체로 바라 보는 것이 옳다는 인식에 바탕하고 있다. 이하에서 자세히 살펴보기로 한다.

2. 사용자 개념 상대성론

(1) 내용

'사용자 개념 상대성론'이란, 집단적 노사관계 즉, 노조법 상의 사용자 개념과 근로계약을 기본 틀로 하는 근기법 상의 사용자 개념이 비록 명문 규정상의 문구는 거의 동일하지만, 그럼에도 불구하고 그 개념범위가 서로 다른 것으로 해석하여야 한다는 주장을 말한다.[6] 즉, 근로계약 차원에서 사용자의 개념은 근로계약 당사자로서의 지위에 국한되지만, 노조와의 협약체결 당사자인 사용자의 개념은 근로계약 존부에 국한되지 않고, 보다 넓은 개념으로 파악하고자 하는 견해이다. 근로3권 질서 상의 수규자로서

---

5) 조경배, "사내하도급에 있어서 원청의 사용자성", 노동법연구, 제25호, 2008, 220면. 같은 취지로 정인섭, "부당노동행위와 노동관계", 노동법연구, 제22호, 2007, 250면 이하.

6) 조경배, "사내하도급에 있어서 원청의 사용자성", 노동법연구, 제25호, 2008, 220면. 같은 취지로 정인섭, "부당노동행위와 노동관계", 노동법연구, 제22호, 2007, 250면 이하.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

사용자 개념을 보다 넓게 인정하고자 하는 이론적 시도라고 할 수 있으므로 흔히 '사용자개념의 확대론'이라고도 칭해지고 있다.[7] 사용자 개념이 개별적 노사관계와 집단적 노사관계에서 각각 달리 파악되어야 한다는 사용자개념 상대성론은 다음과 같은 다양한 법이론적 근거들에 의해 뒷받침되어 있다.

1) 현행 사용자 정의 규정의 열거규정성

우선 사용자 개념에 관하여 근기법 제2조와 노조법 제2조가 문언 상 거의 동일하게 규정되어 있으므로, 그 개념을 달리 파악할 여지가 없다는 지적에 대하여, 사용자개념상대성론을 지지하는 견해는 다음과 같이 반박하고 있다. 즉, 사용자개념 상대성론은, 현행 노조법 상 또는 근기법 상의 사용자 개념에 관한 규정이 일반적인 의미에서의 정의조항이라고 말하기 어렵다고 하여, 이를 반박한다.[8] 현행법상의 근로자 정의조항과는 달리 사용자의 정의에 관한 규정은 그 개념적 징표를 제시하거나 보다 구체적인 의미를 풀이하여 기술하지 않고 단지 그 종류를 나열하고 있는 데 그치고 있다고 주장한다.[9]

2) 노조법상 '근로자'개념의 고유성

사용자 개념의 상대성론은 종래 판례와 학설에서 확고하게 정립해 놓은 근로자개념의 상대성론과 매우 밀접하게 관련되어야 있다. 요컨대 사용자 개념의 상대성론을 근거지우는 방법론으로서 근로자개념과의 '개념적 대칭구조'를 제시하고 있다.

우선 헌법 제32조 제3항을 바탕으로 하여, 근로조건의 기준을 정함으로

---

7) 조경배, 사내하도급에 있어서 원청의 사용자성, 노동법연구 제25호, 2008, 219-220면. 이 글에서 '근기법, 노조법, 민법의 사용자 개념'이라는 소제목으로 설명하고 있으나, 민법 상의 고용계약에서는 '사용자'개념이 등장하지 않으므로, 엄밀하게는 근기법상이 사용자와 노조법 상의 사용자 개념이 있을 뿐이다.

8) 강성태, "지금 왜 사용자인가?", 노동법연구, 제24호, 2008, 15면.

9) 강성태, "지금 왜 사용자인가?", 노동법연구, 제24호, 2008, 15면.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

써 근로자의 기본적 생활을 보장, 향상시키며 균형 있는 국민경제의 발전을 꾀하는 것을 목적으로 하는(근기법 제1조) 근기법 상의 '근로자' 개념은 동법 제2조에 규정되어 있는데, 이에 따르면, '직업의 종류를 불문하고 사업[10] 또는 사업장[11]에 임금을 목적으로 근로[12]를 제공하는 자'를 근로자라고 규정하고 있다.[13] 즉, 근기법 상의 근로자개념은 주로 '근로계약 체결의 일방당사자'로서의 지위에 중심이 놓여져 있다. 이와 달리 노조법 상의 근로자 개념은 주로 '노동조합의 가입주체로서의 지위'에 중점이 놓여져 있다. 그리하여 현행 노조법 제2조 제1호에 따르면, '근로자라 함은 직업의 종류를 불문하고 임금, 급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자를 말한다.'고 한다.

이렇듯 현행 노동법 상의 명문 규정에 비추어 볼 때에도 근로자의 개념이 근로계약 차원에서 또는 근로3권 향유주체라는 관점에서 각각 다르게 파악되어야 한다는 것은 분명해 보인다.[14] 특히 이러한 개념 구별은 근로계약관계의 존부와 관련하여 분명하게 나타난다. 즉, 근로계약관계의 존부가 근기법 상의 근로자 개념 확정에 결정적인 요소라고 한다면, 근로3권의 향유 주체로서 근로자의 개념은, 굳이 근로계약의 체결 여부와 필연적으로 관련성을 가질 필요는 없다고 할 수 있다.[15] 근로3권의 향유주체로서의 적격을 갖는가 하는 것은, 임금이나 기타 수입의 원천이 되는 계약관계의 본질이 무엇인가에 의해 결정되는 것이 아니라, 과연 근로3권을

---

10) 통상 사업은 유기적 관련 하에 사회적 활동으로서 업을 계속적으로 수행하여 가는 기본 단위를 말한다. 법원은 '사업'에 대하여 경영상의 일체를 이루는 하나의 사업조직(법인 또는 개인사업체)을 말한다고 한다(대법원 1993. 2. 9. 선고 91다21381).

11) 사업을 통일적으로 수행하는 독립사업체로서 사업의 목적이나 허가유무 또는 업종을 불문한다.

12) 근기법 제16조 "정신 또는 육체노동".

13) 이 개념은, 최저임금법, 임금채권보장법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 근로자퇴직급여보장법, 근로자참여및협력증진에 관한 법률, 고령자고용촉진법, 장애인고용촉진및직업재활법 상에서 근로자개념과 동일하게 사용된다.

14) 대법원 2006. 5. 11 선고 2005다20910.

15) 임종률, 노동법, 2009, 31면.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

보장하여 줄 필요가 있는가 하는 문제 즉, 단결하도록 하여 줄 필요성이 있는가에 따라 판단되어져야 한다.[16] 만약 이렇게 해석하지 아니하고 근기법과 노조법상 근로자를 동일하게 보면 후술하는 바와 같이 노조법상 근로자의 범위를 너무 좁게 해석하게 되고, 또한 헌법상 노동삼권의 주체로서 근로자와 노조법상 근로자사이에 너무 많은 간격이 발생할 위험성이 있다.[17]

요컨대 사용자개념상대성론은, 결국 근로자 개념이 근기법과 노조법에서 각각 다르다면, 각각의 근로자 개념에 대칭되는 상대방으로서 근기법상의 사용자와 노조법 상의 사용자도 각각 달라야 한다는 것에 착안한 견해라 할 수 있다.

(2) 노조법 사용자개념의 범위설정 이론: '지배력설'

앞서 살펴본 바와 같이, 노조법 상의 사용자 개념을 근기법 상의 사용자 개념과 달리 보는 경우, 여전히 해명해야 할 문제가 남는다. 그것은 바로 노조법 상의 사용자개념 범위를 확정하는 일이다. 즉, 어떠한 징표 또는 사실이 존재할 때 비로소 - 근로계약관계의 존부와 상관없이 - 노조법 상의 사용자 개념에 포섭시킬 것인가가 해명되어야 한다. 이와 관련하여 유력하게 제기되고 있는 견해가 바로 '지배력설'이다.

'지배력설'이란, 근로자와 사이에 직접적인 고용계약관계가 없는 자라고 하더라도 노동관계에 '실질적인 영향력을 미치는 경우'에는 '사용자'로 평

---

16) 노조법상 근로자 개념은 근로계약 상의 상대방인 사용자가 존재하여야 한다는 것과는 차원을 달리 하여 개념 구성되어야 한다. 비록 개별적인 계약 상대방인 사용자가 없다 하여도 노동조합을 결성할 필요성이 있다면 근로자로서의 지위를 인정하여야 한다. 이후 이러한 논의는 자영업자성과 근로자성이 혼합된 소위 특수고용형태의 종사자들에 관한 노동법상의 지위와 관련한 것으로 발전되어 갔다(이에 관한 사례로는 대법원 2005. 11. 24 선고 2005다39136: 학습지 교사와 관련한 이 사건 판결에서는 사용종속관계가 없음을 근거로 노조법 상의 근로자성을 부인하였다).

17) 박수근, "특수고용형태의 근로자성", 2001년 노동법학회 동계발표회, 발표문, 14면.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

가할 수 있어야 한다는 견해이다. 이는 일본 아사히방송(朝日放送) 사건에 대한 일본최고재판소 판결[18]이 계기가 되어, 널리 주목을 받은 바 있다.[19]

3. 사용자개념의 상대성론에 대한 평가와 새로운 시도

지배력설을 중심으로 한 사용자개념의 상대성론은 상당히 의미 있는 견해임에 틀림없다. 그 이유는 다음과 같다.

우리 헌법 제33조에서는 소위 기본권으로서 단결권과 단체교섭권, 그리고 단체행동권을 보장하고 있다. 그런데 이러한 단결권과 단체교섭권 그리고 단체행동권을 침해할 수 있는 주체로서 사용자개념을 바라 볼 때, 굳이 근로계약의 당사자에 국한할 하등의 이유가 없기 때문이다. 다시 말하면, 예컨대 비록 근로계약관계의 당사자로서 사용자의 지위에 놓여 있는 것은 아니지만, 사실상 해당 노동조합의 단결권을 본질적으로 침해하는 자가 있는 경우, 이들을 적극적으로 배제하여, 헌법상 보장된 기본권인 근로3권을 보호할 필요가 있기 때문이다. 이러한 점에서 보면, 사실상 노사관계에 실질적인 영향력을 가지고, 개입할 수 있는 지위에 놓인 자라면, 그들에 대하여는 집단적 노사관계법 상의 사용자 개념에 포섭시킴으로써, 근로3권 보장질서를 견고하게 유지시키는 것이 타당하며, 그러한 점에서 지

---

18) 日最高裁三小判 1995.2.28. 이 사건은 방송사에 파견된 용역업체 근로자가 가입한 노동조합이 단체교섭을 거부한 방송사를 상대로 한 구제신청사건이었다. 이에 대해 법원은 일반적으로 근로계약상이 고용주를 의미하지만, 고용주 외의 사업주라 하더라도 고용주로부터 근로자의 파견을 받아서 자기의 업무에 종사시키고 그의 근로조건에 관하여 고용주와 부분적이라 해도 현실적이면서 구체적으로 지배 결정할 수 있는 지위에 있다면 그러한 경우에 한하여 그 사업주는 사용자에 해당한다고 보았다.

19) 西谷敏, 勞働組合法, 2006, 157面 이하. 하지만 지배력설은 그 구체적 판단 기준이 명확하지 않은 흠이 있다. 즉, 하청기업에 대한 영향력이나 지배력의 범위와 정도를 구체적인 사례에서 판단하는 것은 매우 어렵다. 그러므로 그 판단은 상당히 재량적인 것이 될 위험이 있다. 이러한 이유로 최근에는 일본의 노동위원회나 하급심 법원이 지배력을 근거로 하여 원청회사의 사용자적 지위를 인정하는 것에 대하여 다소 소극적인 태도를 보이고 있다고 한다.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

배력설은 매우 설득력이 있다고 할 것이다.

하지만 지배력설을 중심으로 한 사용자개념 상대성론은 다음과 같은 문제점을 여전히 안고 있다. 그것은 바로 단체교섭제도와 부당노동행위제도 간의 제도적 간극을 고려하지 않았다는 사실이다. 비록 단체교섭 및 협약 관련 제도와 부당노동행위제도가 노조법 상에 놓여져 있는 중요한 제도임은 사실이지만, 양 제도는 기실 그 성격을 상당히 달리하는 것이다. 요컨대 부당노동행위(특히 지배, 개입행위)의 주체로서 사용자 개념과 단체교섭의 의무를 부담하는 사용자의 개념을 같은 차원에서 보는 것은 섬세하지 못한 면이 있다.

판단컨대 근기법 상의 사용자 개념과 노조법 상의 사용자 개념을 같은 것이냐, 다른 것이냐의 논의만큼이나 중요한 것은, 노조법 상 부당노동행위 주체로서 사용자개념과 단체교섭의 당사자로서 사용자 개념이 동일한 것으로 보아, 일원적으로 파악하는 것이 옳은가 여부라고 할 수 있다. 이하에서는 단체교섭의 당사자로서 사용자개념과 부당노동행위의 주체로서 사용자 개념의 구별 필요성을 중심으로 하여, 노동법 상 사용자 개념을 설명하고자 한다.

Ⅲ. 단체교섭제도와 부당노동행위제도 상의 사용자 개념 구별

1. 단결권과 사용자 개념과의 관계

근기법 상의 근로자 개념설명방식은 사용자라는 '계약' 상대방을 전제로 한다. 이와 달리 노조법 상의 근로자 개념은 별도로 사용자의 개념을 필요로 하지 않는 소위 '편면적'인 개념이다.

예컨대 임금을 목적으로 근로를 제공하는 자를 근로자로 보는 근기법상의 근로자 개념은 임금이라는 반대급부와 근로라는 급부 사이의 계약적(=

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

대립적) 관계를 염두에 두고 개념설명을 하고 있지만, 노조법 상의 근로자 개념은 (누구로부터 어떠한 방식이 되었든) 임금, 급료 기타 이에 준하는 금품으로 생활하기만 하면 된다. 이는 단결권의 개념이 실은 상대방을 염두에 둔 개념이 아니라는 것을 보여주는 것이다. 즉, 단결권의 주체로서 근로자의 개념은 상대방으로서의 사용자를 필요로 하지 않는다. 근로계약의 존부가 중요하지 않기 때문이다. 그렇기 때문에 예컨대 실업자로 구성된 노조도 형성될 수 있다고 볼 수 있는 것이다.

2. 단체교섭권과 사용자 개념

단체교섭은 개별 근로자와 사용자 간의 근로계약 내용을 노동조합의 당사자가 되어서 사용자와 확정함으로써, 개별 계약 당사자 간의 계약적 비대등성 문제를 해소해 주는 제도적 수단이다. 다시 말하면 단체교섭은 대립되는 양 당사자로서 사용자와 노동조합이 행하는 것이다. 이러한 단체교섭의 결과로서 합의가 이루어지면, 단체협약이 만들어지고 이러한 단체협약 상의 내용 중 근로조건에 관한 것은 곧 개별 근로자의 근로계약 내용이 된다(이를 단체협약의 '규범적 효력'이라고 한다).

이러한 사실에서 알 수 있는 것은 두 가지이다. 첫 번째는 단체교섭은 반드시 그 상대방을 필요로 한다는 것이다. 즉, 단체교섭은 대립하는 양 당사자를 전제로만 성립되는 개념이다. 두 번째로 단체교섭은 근로조건의 유지 또는 향상을 목적으로 하는 것이다. 즉, 근로계약 상의 내용을 구체적으로 확정하는 작업이다. 이 두 가지 개념 요소를 염두에 둘 경우, 단체교섭제도는 근로계약의 상대방인 사용자의 존재를 반드시 필요로 한다는 것을 알 수 있다. 근로계약의 당사자로서 사용자가 단체교섭에 응함으로써, 결과적으로 근로계약의 내용을 변화시킬 수 있게 되는 것이다.

그러므로 단체교섭제도를 중심으로 하여 보면, 사용자 개념이란, 근로계약관계와 매우 밀접한 것임을 알 수 있다. 이러한 이유 때문에 실업자로 구성된 노조는 단결권을 행사할 수는 있겠지만, 직접 단체교섭을 행사할

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

여지는 없다. 단체교섭의 상대방으로서 사용자를 찾을 수 없기 때문이다. 요컨대 실업자나 구직자 또는 학생들의 경우 근로계약관계가 없기 때문에 근로계약의 내용을 확정하는 것 또한 필요 없으므로, 단체교섭의 상대방인 사용자가 존재하지 아니한다. 결국 근로계약 차원에서의 사용자 개념과 단체교섭제도 상의 사용자 개념은 기본적으로 근로계약관계를 기반으로 하게 된다는 점을 알 수 있다.

3. 부당노동행위제도의 입법목적과 제도적 유래

(1) 부당노동행위제도의 유래

부당노동행위제도는 독일 노동법 상의 제도에서 유래된 것이 아니다. 부당노동행위제도는 1930년대 불안정한 미국의 노사관계에서 등장한 제도이다. 당시 미국 노사관계에서 사용자가 근로자의 단결권, 단체교섭권을 부인하는 불합리한 노사관행에 기인한다는 인식이 확산되면서, 이러한 근로자의 근로3권 질서 침해를 유발하는 사용자의 행위를 금지하기 위하여 와그너법(Wagner Act)을 입법화하면서 시작된 제도이다.[20] 미국의 부당노동행위 제도는 제2차 대전까지는 미국고유의 법제도에 머물러 외국의 노동법제에 영향을 주지 못하였으나, 1947년 인도, 1948년 캐나다의 노사관계쟁의조정법, 1949년 일본에서 노동조합법 개정 시에 미국의 부당노동행위 제도를 도입하게 되었다.

우리나라의 경우는 1953년 3월 8일 노동조합법을 제정하면서, 처음부터 부당노동행위 제도를 도입하여 명문화하여 두었다. 당시에는 근로자가 노동조합에 참가한 것을 이유로 한 해고 등 불이익 취급과 노동조합 조직·가입을 간섭하는 사용자의 행위를 부당노동행위로 규정하고 있었다. 이후

20) 대공황 이후 경제가 회복되면서 노동조합의 권한 남용이 중요한 문제로 대두되자, 1939년에 위스콘신주 등 30여개 주에서 근로자 측의 부당노동행위를 규제하는 입법을 연이어 하였는데, 이에 영향을 받아 1947년 연방법인 태프트하틀리(Taft-Hartley)법에 노동조합과 그 대리인에 의한 부당노동행위도 인정하는 규정을 두기에 이르렀다.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

몇 차례 개정을 하는 과정에서, 예컨대 노조전임자에 대한 급여지원을 명시적으로 부당노동행위(노조법 제81조 제4호)로 한 2010년 1월 개정에 이르기까지 세부적인 변화가 있었지만, 지금까지도 여전히 부당노동행위제도는 지속되고 있다.

⑵ 규정내용

현행 노조법 제81조에서는 '사용자는 그 각 호에서 정하는 부당노동행위를 할 수 없다'고 하고, 부당노동행위의 유형을 명시하여 두는 한편, 부당노동행위판단과 구제에 대한 절차에 대하여는 노조법 제82조부터 제86조에서 규정하고 있다. 이에 따르면 부당노동행위로 인하여 그 권리를 침해당한 근로자 또는 노동조합은 노동위원회를 통한 신속한 구제절차에 따라 구제와 함께 부당노동행위자에 대한 처벌을 할 수 있도록 하고 있다.

⑶ 부당노동행위제도 상의 사용자 개념

1) 부당노동행위제도의 입법목적

노조법 상의 부당노동행위제도는 헌법이 규정하는 근로3권을 구체적으로 확보하고 집단적 노사관계의 질서를 파괴하는 사용자의 행위를 예방·제거함으로써 근로자의 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 확보하여 노사관계의 질서를 신속하게 정상화하기 위하여 노조법 상에서 특별히 규정하여 둔 것이다.[21] 예컨대 노동조합의 조직·활동에 대응하여 사용자가 이를 주도한 근로자를 해고하는 등 불이익을 주었다면, 이는 헌법 제33조가 보장하고 있는 근로3권 질서 자체를 본질적으로 해하는 결과를 가져온다. 이에 따라 벌칙을 가함으로써, 근로3권 질서의 침해를 막고자 하는 데 부당노동행위제도의 본질이 있다.

2) 부당노동행위제도의 이질성

---

21) 대법원 1993.12.21,선고 93다11463; 대법원 1998.5.8, 97누7448판결.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

현행 노조법 체계는 헌법상의 근로3권 질서를 구체화해 놓은 것이다. 헌법상의 근로3권 질서는 단결권과 단체교섭권 그리고 단체행동권 보장을 내용으로 한다. 그리고 집단적 노사관계법은 당사자대등성의 원칙(Grundsatz der Parität)[22]과 국가중립의무원칙(Neutralitätspflicht)를 그 배경으로 하게 된다. 단결권을 행사하여, 노동조합을 결성한 이상, 사용자와 노동조합은 대등한 당사자이기 때문에, 사적 자치원리가 지배하게 되고, 국가가 개입할 여지는 없다고 본 결과이다.[23] 만약 노동조합이 결성됨으로써 이미 사용자와 노조 간에는 계약(협약)적 대등성이 확보되었음에도 불구하고, 특별히 국가가 나서서 어느 편을 지원한다면, 이는 오히려 계약(협약)적 대등성을 깨는 것이 된다.

이러한 점을 염두에 둔다면, 현행 노조법 제81조 이하에서 규정하고 있는 부당노동행위제도는 노조의 결성을 단결권 보장을 통해 보장하였음에도 불구하고, 추가적으로 국가의 적극적인 보호역할을 구현하는 것이다. 노동조합과 사용자 간의 비대등성을 전제로 하고 있다고도 할 수 있다. 이러한 한도에서 부당노동행위제도는 근로3권 질서, - 그러니까 전통적인 독일식 단결권 질서 -와는 상당히 이질적인 제도임을 알 수 있다.[24]

3) 제3자에 의한 부당노동행위의 가능성

---

22) 쟁의행위를 통해 실현하고자 하는 것이 근로관계 당사자 사이에서의 유리한 조건을 규율하기 위한 데 있으므로, 양 당사자가 대등하게 자신의 실력을 과시할 기회를 균등하게 가질 수 있어야 한다. 이를 당사자 대등성의 원칙(Grundsatz der Parität)이라고 한다. 요컨대 근로자 측에 단결할 수 있는 기본권을 특별히 인정하여 준 것은, 개별적 근로계약관계 상에서 결여되어 있는 계약당사자 간의 비대등성을 극복하도록 하기 위한 것이다. 따라서 노동조합이라는 조직을 통해서 단체협약관계에서의 양 당사자는 실질적인 대등성 확보를 구현하게 된다.

23) BVerfGE 4, 96, 107; Gamillscheg, Kollektives Arbeitsrecht Bd.1, 1996, S.980ff.; Birk/Konzen/Raiser/Löwische/Seiter, 집단적 노사분쟁의 규율에 관한 법률(김형배 역), 1990, 16면.

24) 이러한 이유 때문에 실은 -우리나라의 집단적 노사관계법 체계가 모델로 하고 있는 - 독일의 경우에는 부당노동행위제도가 아예 없으며, 부당노동행위제도는 영미식 제도에서 유래된 것임은 쉽게 짐작될 수 있다.

노조법 상 명문으로 드러난 바에 따르면 부당노동행위의 주체는 '사용자'이다. 다시 말하면 부당노동행위금지의 수규자이면서 동시에 구제명령의 피신청인이 바로 사용자가 된다. 그렇다면 이때 사용자의 개념범위로서 부당노동행위금지의 수규자는 어떠한 범위에서 까지 인정될 수 있을까?

이 문제와 관련하여 입법 형식상으로나 문언 상 근로계약관계나 단체교섭관계에 있어 사용자 개념과 동일하게 볼 수도 있을 것이다.

하지만 부당노동행위 주체로서 사용자 개념을 해석함에 있어, 근로계약관계의 당사자로 국한하는 것은 지나치게 형식적이며, 동시에 부당노동행위제도의 입법목적과도 잘 조화되지 못한다. 왜냐하면 근로계약의 당사자가 아니더라도 근로3권 질서가 본질적으로 훼손되는 일이 발생할 수 있기 때문이다. 특히 부당노동행위 중 지배, 개입행위의 경우는 더욱 그러하다. 이와 관련하여 과거 위헌논란의 중심에 있던 구 노동쟁의조정법 제13조의 2 규정을 되새겨 볼 필요가 있다. 동 규정에 따르면, "직접 근로관계를 맺고 있는 근로자나 당해 노동조합 또는 사용자 기타 법령에 의하여 정당한 권한을 가진 자를 제외하고는 누구든지 쟁의행위에 관하여 관계 당사자를 조종, 선동, 방해하거나 기타 이에 영향을 미칠 목적으로 개입하는 행위를 하여서는 아니 된다. 다만. 총연합단체인 노동조합 또는 당해 노동조합이 가입한 산업별 연합단체인 노동조합의 경우에는 제3자 개입으로 보지 아니한다." 고 규정하고 있었다. 또한 구 노동쟁의조정법 제45조의2에는 이 규정을 위반하여 구노동쟁의조정법 제13조의 2 규정을 위반한 제3자에 대하여 7년 이하의 징역 또는 1,000만 원 이하의 벌금에 처하도록 하고 있었다.[25]

---

25) 종래 제3자 개입금지 규정은 많은 위헌논란을 불러 일으켰던 바가 있다. 그러한 지적 가운데에는, i) 노동3권은 자주적으로 결정되고 행해질 문제이므로 그것이 면책의 범위를 벗어나는 범죄행위가 되지 않는 한 제3자의 개입을 받든 안 받든 당사자가 자주적으로 결정할 문제이지 법률이 끼어 들어서는 안되며, ii) 노사문제의 자구적 해결은 제3자의 관여에 의해서가 아니라 오히려 정부의 긴급조정, 직권중재 등 부당한 제도적 개입과 설립신고서를 반려하는 구청, 농성장에서 노동자들을 끌어내고 구사대의 폭행을 방조하는 경찰, 무노동무임금 지침, 경영권, 인사권 단체교섭 사항에서의 제외지침 등을 남발하고 위 지침을 어긴 사용주는

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

이 규정의 위헌성에도 불구하고, 한가지 오늘날 우리에게 시사해 주는 한가지가 있다. 그것은 바로 노사 양 당사자만이 아니라 제3자에 의해서도 근로3권 질서가 훼손될 수 있다는 것을 이미 노동법의 입법자도 어느 정도 예상하고 있었음을 보여주고 있다는 사실이다.

4) 소결

판단컨대 부당노동행위제도는 장래에 향하여 노동3권의 구체적 실현을 통한 공정한 노사관계질서의 확립을 꾀하려는 데 그 취지가 있는 것이므로 근로계약의 당사자로서 또는 단체교섭의 당사자로서의 사용자 개념보다는 넓게 인정되어져야 한다.[26)]

구체적으로 보면, 부당노동행위로서 노조법에 열거된 행위의 유형 중에는 근로계약 상의 당사자로서 사용자 개념과 동일한 것으로 보아야 할 때도 있다. 단체교섭의 거부행위에 대한 부당노동행위가 그러한 경우다. 단체교섭에 응한다는 것 자체가 근로계약관계와 괴리되어 파악될 수 없는 행위이기 때문이다. 이와 달리 노동조합에 대한 지배, 개입행위의 경우는 달리 파악되어야 한다. 이러한 경우는 반드시 근로계약 상의 사용자만에 의해 행하여지는 것으로 단정하기 어렵기 때문이다.

불이익조치하겠다고 협박하며, 전노협 가입노조에만 선별적으로 업무조사권을 발동하는 등으로 노조활동을 탄압하는 노동부의 부당한 개입행위에 의하여 훼손되고 있다는 점 때문이었다. 즉, 노조의 자주적인 요청에 의한 제3자의 관여행위를 법률로 금지하는 것이야말로 노조의 자주성을 해치는 것으로 보여졌기 때문이다.

26) 대법원 2010. 3. 25, 선고 2007두8881; 미국의 연방노동관계위원회(NLRB, National Labor Relations Board)에서도 사업자들 간의 내부적 관계, 다시 말해 공동의 경영이나 공동의 노동관계에 대한 중앙 집중화된 지휘, 통제 및 공동의 소유관계 등을 기준으로 형식상 분리되어 있는 여러 사업들을 하나의 사업으로 보기 위해서 여러 사업기관들을 하나의 통일된 사업이라고 결정하는 이른바 단일사용자원칙(a single integrated employer)을 채택하여 사용자개념을 확대하였다고 한다(이에 대하여 자세히는 김용대, 사용자 범위의 확대에 관한 법리, 숭실대학교 박사학위 논문, 1998, 25면); 박수근, 간접고용근로자의 집단적 노동분쟁과 쟁점의 검토, 노동법연구, 제24호, 2008, 44면 이하; 조경배, 사내하도급에 있어서 원청의 사용자성, 노동법연구 제25호, 2008, 220-221면.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

4. 평가 및 소결

최근 노동법 상 사용자 개념 확대에 관한 논의가 시작된 실제적인 배경을 살펴보면, 부당노동행위제도와 대단히 밀접한 관계를 가지고 있다. 직접적인 근로계약의 당사자인 하청회사 사용자만이 아니라 제3자인 원청회사 사업주에 대하여도 부당노동행위책임을 물을 수 있도록 사용자 개념을 확대하려는 것이, 바로 사용자 개념의 상대성론 혹은 사용자 개념 확대론의 등장 배경이기 때문이다.[27]

현행 노조법 제81조에서는 '사용자는 그 각 호에서 정하는 부당노동행위를 할 수 없다'고 하고, 부당노동행위의 유형을 명시하여 두는 한편, 부당노동행위판단과 구제에 대한 절차에 대하여는 노조법 제82조부터 제86조에서 규정하고 있다. 이에 따르면 부당노동행위로 인하여 그 권리를 침해당한 근로자 또는 노동조합은 노동위원회를 통한 신속한 구제절차에 따라 구제와 함께 부당행위자에 대한 처벌을 할 수 있도록 하고 있다. 노조법 상의 부당노동행위제도는 헌법이 규정하는 근로3권을 구체적으로 확보하고 집단적 노사관계의 질서를 파괴하는 사용자의 행위를 예방·제거함으로써 근로자의 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 확보하여 노사관계의 질서를 신속하게 정상화하기 위하여 노조법 상에서 특별히 규정하여 둔 것이다.[28]

비록 사용자가 아닌 제3자의 협약자치질서 침해행위는 현행 노조법 상 처벌할 수는 없지만, 이러한 협약자치질서에의 위해가 바람직하지 않음은 물론이다. 그리고 여전히 제3자에 의한 협약자치질서의 침해 가능성은 얼마든지 상존하고 있다. 특히 원하청관계에서 원청회사의 하청회사노동조합에 대한 지배, 개입 행위에 대하여, 원청회사에를 하청근로자에 대한 사용자의 지위에 있다고 해석하는 것이나, 학계에서 사용자 개념을 확대하여야

---

27) 사용자 개념의 상대성 즉, 사용자 개념을 확대하여야 한다고 주장하는 입장은 부당노동행위제도의 실효성을 보장하기 위한 데 있다(조경배, 사내하도급에 있어서 원청의 사용자성, 노동법연구 제25호, 2008, 219면).

28) 대법원 1993.12.21,선고 93다11463; 대법원 1998.5.8, 97누7448판결.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

한다는 주장은, 사실 이러한 제3자의 협약자치질서 침해행위를 막기 위한 것이다. 사용자와 유사한 지위에 놓은 제3자의 단체협약질서 파괴행위에 대하여 적극적으로 대응할 필요가 있고, 법원으로서는 이러한 필요를, 사용자개념의 확대론을 통해 충족시키고 있는 것이라 판단된다. 즉, 하청노동조합의 근로3권 침해행위의 주체로서, 사용자의 개념을 원청회사 사용자에게로 까지 넓게 해석함으로써, 원청회사 사용자에 의한 협약자치질서에의 침해행위를 막을 필요가 있었던 것이었다. 그러므로 현행 노조법 제81조 상의 부당노동행위 유형 가운데, 4호 상의 지배행위나 개입행위의 주체로서 '사용자'의 개념은 본래부터 '어느 정도 사용자와 유사한 지위에서 노사 협약자치질서를 실질적으로 침해할 수 있는 지위에 놓인 제3자'에게로 까지 개념 포섭될 가능성이 처음부터 내재되어 있었던 것으로 볼 수 있다.

이는 다른 한편에서 보면, 부당노동행위로서 지배, 개입의 주체인 사용자와 단체교섭의 당사자로서의 단체교섭'의무'를 부담하여야 하는 사용자와는 그 개념의 폭이 처음부터 다르다는 것을 보여주는 것이기도 하다.

단체교섭제도란 근로조건의 형성 가능성과 분리해서 생각할 수 없다. 최근 제기되고 있는 지배력설도, 하청회사에 지배력을 가지기 때문에 사용자로서의 지위에 놓인다기 보다는 제3자가 - 마치 파견근로자에 대한 사용사업주와도 같이 - 하청근로자의 근로조건의 일부 또는 전부를 결정할 수 있는 지위에 놓이는 경우에 비로소 사용자의 지위를 인정하는 견해이다. 그러므로 근로조건을 결정할 수 있는 지위의 자가 아니라면 처음부터 단체교섭의 상대방인 사용자라고 할 수 없는 것이다. 따라서 제3자가 명시적인 근로계약의 체결을 하지 아니한 경우라도 단체교섭 상의 사용자로서 지위가 인정되기 위해서는 그 제3자가 단순히 근로자들에 대해 지배적 지위에 있는 데 그치지 않고, 그 근로자들의 근로조건을 -전부 또는 일부라도- 결정하는 자여야 한다.[29]

---

29) 土田道夫, "下請企業の勞働者にする對受入企業の團体交涉上の使用者性", ジュリスト, No.1075, 1995. 9, 147面.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

Ⅳ. 지배개입 행위에 따른 원청회사의 부당노동행위 주체로서의 지위 여부

1. 판례의 내용과 평가

최근 하청회사노조가 원청회사를 상대로 하여 지배개입행위에 따른 부당노동행위 구제신청사건에서, 대법원이 부당노동행위임을 확인하는 판결이 있었다. 이 판결은 노사 간 협약자치질서를 침해할 수 있는 지위에 있는 자가 직접적인 근로계약 상의 당사자로서 사용자만이 아니라, 제3자일 수도 있다는 점을 고민한 경우라고 할 수 있다. 실제로 부당노동행위의 유형 중 지배, 개입행위가 갖는 속성 상 그러한 행위는 사실 근로계약관계의 직접적인 당사자가 아니라 하더라도, 얼마든지 행하여질 수 있기 때문이다. 이를 방치하면 근로3권을 보장하고 있는 헌법적 요구를 무시하는 것이 된다. 이러한 현실적 문제에 직면하여, 법원이 지배개입행위의 사용자 개념은 어느 정도 포괄적으로 파악하여, 기존의 부당노동행위 제도를 활용하여 그러한 지배, 개입행위를 막고자 한 것으로 이해하여야 한다. 그러므로 이 판결에서 원청회사의 지배, 개입행위가 부당노동행위라고 하는 것은 하청회사 노사의 협약자치질서를 보호하기 위하여 행한 불가피한 해석방법의 결과라고 할 수 있다.

2. 법리적 문제점과 입법정책론적 과제

현행 노조법 상의 부당노동행위제도는 사용자의 부당노동행위에 대하여 형벌을 과하도록 하고 있다. 예컨대 부당노동행위에 대한 노동위원회의 구제명령이 확정되거나 행정소송을 제기하여 확정된 그 구제명령을 위반한 자에 대해서 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금을 과하고, 부당노동행위 각 호에 해당하는 부당노동행위를 한 자에 대하여는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금을 부과하도록 하고 있다.[30]

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

그리고 부당노동행위제도 상의 사용자 개념은 노동조합의 근로3권 침해를 유발하는 경우, 반드시 그 주체가 근로계약상의 당사자에 국한될 필요가 없음을 지적한 바 있다. 이러한 한도에서 최근 원청회사가 하청회사 노동조합 측에 대한 지배개입행위를 한 것에 대하여, 법원이 부당노동행위 책임을 물은 데 대하여 일응 타당하다는 지적을 한 바 있다.

하지만 이러한 판례의 입장을 염두에 둘 때 여전히 해결해야 할 입법정책적 과제를 언급하지 않을 수 없다.

(1) 죄형법정주의

우선 현행 부당노동행위제도는 앞서 언급한 바와 같이 형벌주의를 취하고 있다. 이러한 형벌주의는 사실 협약자치질서가 지배하는 집단적 노사관계에 어울리지 않는다. 무엇보다 죄형법정주의원리에 비추어서도 그러하다. 역동적인 노사관계의 성격상 부당노동행위규정은 추상적이고 애매하다고 볼 수 있다. 이러한 추상적인 규정을 구성요건으로 하는 처벌규정은 그 자체로 기능하기 어렵게 된다. 부당노동행위는 절도나 횡령과 같이 전형적인 범죄유형과는 사뭇 달라서, 아직 그 행위유형이 고정되어 있지 않다. 다시 말하면 구성요건해당성에 대한 요소 포착이 정형화되어 있지 않

30) 이러한 형벌주의는 이미 1953년에 제정된 노동조합법과 노동쟁의조정법에서부터 채택된 것이었다. 제정 당시 노조법에 따르면, 사용자의 간섭행위(구 노동조합법 제10조 제1항), 차별대우(구 노조법 제10조 제2항, 노동쟁의조정법 제10조), 단체교섭거부(노동조합법 제34조)를 사용자의 부당노동행위로서 금지하는 한편, 노동조합의 단체협약의 거부(동 제34조 2항)도 노동조합의 부당노동행위로서 금지하여 부당노동행위를 하는 노사 쌍방에 대해 처벌주의를 취하였다. 물론 1963년 제3공화국에서는 노동조합법을 개정하여 노동조합 측의 부당노동행위를 삭제하고 또 부당노동행위에 대한 처벌주의를 원상회복주의로 전환하였던 바 있지만, 1986년 노동관계법의 개정에서는 노동계의 요구에 의해 부당노동행위에 대한 종래의 원상회복주의에 덧붙여서 처벌주의가 병존적으로 도입되었다. 그 후에도 노동관계법이 몇 차례 개정되었음에도 불구하고, 이러한 부당노동행위에 대하여 형벌주의를 취하고 있는 것은 변함이 없다(이에 대하여 자세히는 강희원, 부당노동행위제도의 실효성 제고 및 형벌규정 개선방안, 노동부 용역보고서(2005), 177면 이하 참고).

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

다. 그러므로 부당노동행위로서 열거된 행위를 형벌의 적용을 받는 범죄로서 규정하면, 실제로 형벌이 과해질 수 있는 부당노동행위란, 매우 소극적이면서도 엄격히 제한된 범위 내에서만 인정될 수 있어야 한다. 따라서 노동관계이기 때문에 상대적으로 손쉽게 부당노동행위를 판단하여서는 안된다.[31]

(2) 비범죄화

본질적으로 현행 부당노동행위제도관련 법규정이 갖는 문제점은, 사인의 부당노동행위를 아예 범죄행위로 파악하도록 하는 데 있다. 이는 범죄화의 범위를 지나치게 넓히는 것이므로, 비범죄화라는 현대적 경향에 반하는 것이고, 나아가 형벌만능주의로 이어질 우려가 농후하다고 볼 수 있다.[32] 따라서 부당노동행위제도가 노사관계 현실에 비추어 여전히 필요한 것이라 하더라도, 굳이 형벌을 그 법률효과로 하는 것은 바람직하다. 형벌주의가 가지는 강력한 예방효력과 촉구적 기능을 고려하더라도 이는 지나친 것이 아닐 수 없다. 오히려 부당노동행위제도가 다변화하는 노동관계에서 원래의 제 기능을 충분히 발휘하기 위해서라면, 부당노동행위에 따른 법적 결과의 원상회복에 보다 집중하여야 하고, 제재가 필요하다면 행정벌 형식을 취하는 것이 입법론적으로 바람직하다고 판단된다.

요컨대 부당노동행위제도는 형벌을 그 내용으로 하고 있는 바, 과연 그 규정이 형벌의 최후수단성이나 규정명확성원칙에 부합하는 것인지 의문이다. 그 만큼 부당노동행위제도는 그 해석과 적용에 있어 매우 엄격하여야 한다.

3. 소결 및 평가

---

31) 같은 취지로 강희원, 부당노동행위제도의 실효성 제고 및 형벌규정 개선방안, 노동부 용역보고서(2005), 192면 이하.

32) 노동형법이 갖는 법이론적 문제점에 대하여 자세히는 莊子邦雄『勞働刑法(總論)[新版]』(有斐閣) 1979, 1면 참조

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

지배개입행위라는 부당노동행위의 주체는 근로계약을 전제로 한 사용자 개념에 국한될 필요가 없다. 원하청관계에서 사용자의 개념 확장 논의가 유독 부당노동행위 규정의 확대 적용을 위한 것이라면, 이는 부당노동행위 제도의 전반적인 수정을 동반하여야만 설득력을 가질 수 있다. 왜냐하면 현행 노조법상의 부당노동행위제도는 그 위반에 따른 법적 효과로서 형벌 부과를 예정하고 있는 데, 형사범죄의 행위 주체를 함부로 확장하여 개념 포섭하는 것은 죄형법정주의원칙에 배치될 수 있기 때문이다. 배려의무차원에서 일정한 사법상의 계약의무를 부담시키기 위해 사용자 개념을 확장하는 논의에 대하여는 고려할 수 있겠지만, 형사적 불이익을 내용으로 하는 경우는 다르게 보아야 한다. 형사처벌을 내용으로 하는 규정을 적용하기 위해 그 행위 주체를 법이론적으로 개념상 확대하는 것은 법 일반원리에 비추어서도 납득하기 어렵기 때문이다. 적어도 입법론적으로는 부당노동행위제도를 형벌주의와 연결하여 두는 것은 개선되어야 한다고 본다. 이러한 점에서 일본에서의 사용자개념 확대 논의는 우리의 그것보다 훨씬 더 설득력을 가질 수 있다고 본다. 왜냐하면 일본의 경우, 부당노동행위제도를 두고 있지만, 형벌주의를 취하지 않고 있다.

Ⅴ. 요약 및 결론

1. 현행 노조법 상의 부당노동행위제도는 미국에서 유래된 제도로서 현재 우리 노조법 상에서는 '약한' 노동조합을 전제로 하고 있다. 다른 한편 현행 노조법 상의 노동조합설립과 운영(단결권), 그리고 단체교섭과 단체협약 및 쟁의행위 등은 독일식 협약자치질서를 배경으로 하고 있다. 그런데 현행 노조법 상 사용자 개념은 동법 제2조 제2호에서 일원적으로 규정해 놓음으로써, 혼란을 유발하고 있다. 단체협약의 당사자로서 사용자 개념과 부당노동행위의 주체로서 사용자 개념이 동일하다는 볼 여지가 크기 때문이다.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

2. 단체교섭의 당사자로서 사용자 개념은 근로계약관계를 중요한 매개로 한다. 왜냐하면 단체교섭은 노동조합이라는 조직이 개별 근로자의 근로계약 내용을 -규범적 효력을 통해 - 유리한 방향으로 변경시켜 주는 것을 주된 목적으로 하기 때문이다. 따라서 근로계약의 내용을 변경하는 데 아무런 권한을 가지지 못하는 자라면 단체교섭의 사용자 개념에 포섭될 수 없다고 보아야 한다.

3. 다른 한편 부당노동행위제도 상의 사용자 개념은 달리 보아야 한다. 부당노동행위제도는 '약한' 노동조합에 대한 근로3권 침해행위를 국가가 막아주겠다는 것을 본질로 한다. 그런데 문제는 노동조합의 근로3권을 침해하는 행위가 오로지 근로계약 상의 사용자만에 의해 행하여 지는 것은 아니라는 점이다. 특히 하청근로자로 구성된 노동조합에 대하여 지배, 개입행위를 통해 근로3권이 침해하는 것은, 오로지 하청회사 사용자만이 아니라 원청회사를 통해서도 발생할 수 있다. 이러한 경우에 사용자 개념을 단지 근로계약관계의 존부 차원에서 제한적으로 바라보는 것은, 근로3권 보장이라는 헌법적 가치를 외면하는 것이 되고 만다. 이러한 점에서, 부당노동행위제도 상의 사용자 개념을 근기법 상의 사용자 개념에 비해 확대하는 것은 해석상 타당하다고 본다. 하지만 이것이 곧 단체교섭의 상대방인 사용자 개념이 당연히 확대될 수 있다는 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 다만 부당노동행위제도에 대하여 형벌주의를 취하고 있는 우리 현행 노조법의 개선이 필요해 보인다. 부당노동행위의 주체로서 사용자의 개념을 확대하는 것을 지지하는 한, 더욱 그러하다. 왜냐하면 해석을 통해 형사범죄자의 범위를 확대하는 것은 죄형법정주의에 반할 우려가 있기 때문이다. 이러한 점에서 집단적 노사관계법 상의 사용자 개념 확대론이 쟁점이 되고 있는 일본은 우리의 경우와 다소 다르다. 왜냐하면 일본은 부당노동행위제도가 형벌주의를 취하고 있지 않기 때문이다. 따라서 일본에서의 사용자개념확대론은 우리의 경우보다 훨씬 설득력이 높다고 보여진다.

5. 결론컨대 부당노동행위의 유형 중 지배, 개입행위는, 사용자나 노동조합에 대하여 막대한 영향력을 실질적으로 가지고 있거나, 혹은 해당 회

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

사와의 거래관계 때문에 해당 기업의 노사관계 안정이 자신의 이익과 매우 밀접하게 관련되어 있는 제3자에 의해서도 행하여질 수 있다. 이러한 관점에서 보면 원하청관계에서 원청회사는 하청회사 노사관계에 있어 제3자에 불과하지만, 부당노동행위의 주체인 사용자 개념에 포섭될 수 있다는 우리 법원의 입장은 일응 타당하다. 하지만 부당노동행위의 유형들 가운데 단체교섭의 거부나 해태행위의 주체가 되는 사용자의 개념은 지배, 개입행위의 주체와 그 범위를 달리 한다고 보아야한다. 다만 예외적으로 하청회사가 경영주체로서 아예 실체를 가지지 않는 경우 등과 같이 원청회사와 하청근로자 간에 직접적인 근로계약관계가 성립되었다고 볼 수 있는 경우에 한하여 단체교섭의 당사자성이 인정될 수 있을 것이다.

주제어: 사용자개념, 협약자치원리, 부당노동행위, 사용자개념 확대, 단결권

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

참고문헌

강성태, “지금 왜 사용자인가”,「노동법연구」제24호, 서울대학교 노동법연구회, 2008.

_____, "위법한 파견근로와 사용사업주의 책임", 「노동법연구」 제13호, 서울대노동법연구회, 2002.

강희원, “용역계약의 해지가 근로관계의 자동소멸사유인가?”, 「노동법학」제36호, 한국노동법학회, 2010.

권혁,『노동유연화와 해고보호법』, 집문당, 2010

김영문, “사내하도급 근로자들의 원청기업에 대한 단체교섭 가부”,「노동법학」제36호, 한국노동법학회, 2010.

김형배, “노동법과 사법질서”, 현민유진오박사 고희기념학술논문집, 1975,

문무기, “간접고용(근로자공급 하도급 파견 용역)규율의 법리”,『월간노동리뷰』제4호, 2005. 4.

박수근, “간접고용근로자의 집단적 노동분쟁과 쟁점의 검토 : 최근 발생한 중요한 사례를 중심으로”,「노동법연구」제24호, 서울대학교 노동법연구회, 2008.

_____, "위장도급과 불법파견에 있어 고용관계,"『노동법률』제150호, 중앙경제사, 2003.

박종희, “사내하도급과 파견의 구별기준 및 불법파견의 법률효과”,『조정과 심판』2010 가을, 중앙노동위원회, 2010.

박지순,「간접고용 실태 및 법·제도 개선 과제」(전태일 주간기념 민주노총 정책토론회 자료집), 전국민주노동조합총연맹, 2008. 11.

유정엽, “정부의 비정규직법 개정안에 대한 한국노총 입장”, 비정규직법 개정에 관한 토론회, 국가인권위원회, 2009. 4.

은수미, “비정규직 하위유형의 변화와 전망”,「고용유연화와 비정규고용」, 한국노동연구원, 2008.

이재용, 간접고용의 법적 규율에 관한 연구: 파견근로자보호등에관한법률

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

의 문제점과 개선방안을 중심으로, 연세대학교박사학위논문, 2003.
이철수, “아웃소싱의 법리”,『기업의 구조조정과 노동법적 과제』, 한국노동연구원, 1998.
조경배, “사내하도급에 있어서 원청의 사용자성 - 간접고용을 중심으로”,「노동법연구」제25호, 서울대학교 노동법연구회, 2008.
최홍엽, “독일근로자파견법의 개정배경과 내용”, 『노동법연구』제15호, 2003,

山口浩一郎, 事業場内下請における派遣勞働者と派遣先企業との雇用關係の存否, 判例評論 273号(判例時報 1013号).
馬渡淳一郎, 勞働者派遣法と三者間勞務供給契約, 季刊勞働法 157号, 1990.
砂山克彦, 派遣勞働の實態と二重の勞働契約論, 勞働保護法の研究(外尾健一先生古稀記念論文集), 有斐閣, 1993.
菅野和夫,『勞働法』(第7版), 弘文堂, 2005.
白井邦彦, 過剰雇傭と流動化政策, 季 勞働總研クォ-タリ- 37号, 2000.
藤本眞, 請負企業の經營と人事勞務管理, 人材ビジネス 217号, 2004.
藤本眞, 製造現場における業務請負活用の實態と課題, Business Labor Trend 2005. 2.
國武輝久, 勞働者派遣法と勞働法上の使用者概念, 季刊勞働法 137号, 1986.
脇田 滋, 韓國と日本の勞働者派遣法・日本の側からの比較, 季刊勞働法 188号, 1999.
濱口桂一郎, 勞働者派遣と請負の間 - 建設業務と製造業務 -, 季刊勞働法 209号, 2005.
浜村 彰, 改正勞働者派遣法の檢討, 勞働法律旬報 第1554号, 2003.

Becker, Abgrenzung der Arbeitnehmerüberlassung gegenüber Werk- und Dienstverträgen, DB 1988, 2561 ff.
Boemke/Föhr, Arbeitsformen der Zukunft, 2000.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

Dauner-Lieb, Verbraucherschutz durch Ausbildung eines Sonderprivatrechts für Verbraucher, Berlin 1983.

Göbel, Arbeitnehmerüberlassung, Werkvertrag und vorgeschobene Arbeitgeberrisiken(II), BLStSozAfbR 1973, 324.

Haman, Die Grenze zwischen illegaler Arbeitnehmerüberlassung und erlaubtem Fremdpersonaleinsatz im Rahmen von Dienst- und Werkverträge, WiVerW 1996, 212.

_____, Erkennungsmerkmale der illegalen Arbeitnehmerüberlassung in Form von Scheindienst- und Scheinwerkverträgen, Diss.(Münster), 1994.

_____, Fremdpersonal im Unternehmen - Alternativen zum Arbeitsvertrag, 2. Aufl., 2003.

Wank, Das Recht auf Arbeit im Verfassungsrecht und im Arbeitsrecht, Königstein 1980.

Weber, Das aufgespaltene Arbeitsverhältnis, 1992.

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

<Abstract>

Re-Analyse von der Arbeitsgeberbegriffslehre in Korea

Kwon, Hyuk*

Im Individualarbeitsrecht ist der Arbeitgeber vergleichsweise leicht auszumachen: Er definiert sich durch das Vertragsverhältnis mit einem Arbeitnehmer, den Arbeitsvertrag. Schwieriger scheint es sich im Kollektivrecht zu verhalten. Hier werden tatsächlich immer häufiger mühsame Suchvorgänge notwendig, um herauszufinden, wer als Arbeitgeber Partner der Gewerkschaft ist. Vertragsarbeitgeber behalten ihre Funktionen. Daneben gibt es aber noch etwas, das man als gewillkürten Betriebsarbeitgeber bezeichnen könnte, nämlich die durch eine Führungsvereinbarung geschaffene gemeinsame Betriebsleitung.

Eine effektive Zusammenarbeit ist nur möglich, wenn der Einsatz des Fremdpersonals mit dem Betriebsablauf des Bestellers abgestimmt wird. Hierfür wird das „Werk„ bis hin zur Gestaltung einzelner Arbeitsschritte so detailliert vertraglich festgelegt, daß dem Werkunternehmer in der vertraglichen Durchführungsphase kein beachtlicher eigener Entscheidungsspielraum mehr verbleibt. Dies ermöglicht dauerhafte Aufgabenerfüllungen. Äußerliche Unterschiede zwischen der Tätigkeit des Stamm- und des Fremdpersonals sind nicht mehr festzustellen.

In Koreanischem Kollektivesarbeitsrecht gibt es sog. Unfair Practice für die Sicherung des Koalitionsrechts von Gewerkschaft. Hierbei geht es um die Begriff des Arbeitsgebers, der durch dem Gesetz zu strafen ist. Dieser

* Professor of Law School, Pusan National University

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM

Arbeitsgeberbegriff ist von dem Arbeitsgeberbegriff zu differenzieren, der in der typische Tariffautonomie zwischen Arbeitsgeber und Gewerkschaft. Insoweit ist die Erweiterung des Arbeitsnehmerbegriffs zu bejahen, weil die Koalitionsfreiheit von dritte beeintrachtigt werden kann. Aber es ist zu verneinen, dass die Begriff des Arbeitsgebers im Tariffbindungsbereich zu erweitern ist, unabhängig von der Bestehene des Arbeitsvertrags.

Key words: Arbeitsgeberbegriff, Tarifautonomie, unfair labor practices, Erweiterung des Arbeitsgebersbegriffs, Koalitionsrecht

[Provider:earticle] Download by IP 211.231.XXX.XX7 at Wednesday, April 15, 2026 9:55 PM